

1500468-97.2021.8.26.0568

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/07/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, no dia 9 de março de 2021, por volta das 18h15min, na residência situada na r. Afonso Bittar, 10, Vila Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500468-97.2021.8.26.0568 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500468-97.2021.8.26.0568

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067380/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 16680933 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 936/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2067380 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA DIAS DE FREITAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaní Cristina Mendes Marum

Vistos.

GUSTAVO DE SOUZA LEOPOLDINO e GABRIELA DIAS DE FREITAS foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei 11.343/06, em razão

de em data e local não apurados, mas antes do dia 9 de março de 2021, nesta cidade e Comarca, terem se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, no dia 9 de março de 2021, por volta das 18h15min, na residência situada na r. Afonso Bittar, 10, Vila Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cerca de 22g de "Cannabis sativa L." e 28g de cocaína, substâncias essas que causam dependência física e psíquica.

Os acusados foram presos em flagrante, sendo-lhes concedida liberdade provisória.

Os acusados foram notificados e depois de apresentarem defesa preliminar, foi a denúncia recebida em 9 de agosto de 2021, sendo determinada a citação dos réus.

No curso da instrução foram inquiridas as testemunhas arroladas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a absolvição dos acusados em relação ao delito de associação, e a condenação dos acusados pelo delito de tráfico.

A Defensoria, a seu turno, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Tóxicos, e subsidiariamente, requereu a redução e fixação da pena e regime prisional com menor rigor.

É o relatório.

Decido.

Na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado negou os fatos a ele atribuídos e relatou que não pratica o tráfico de drogas, sendo usuário de cocaína e maconha. Disse, ainda, que o dinheiro apreendido em sua casa é proveniente do seu trabalho e do de sua companheira (fls. 5).

Em juízo, o réu reiterou que as drogas apreendidas em sua casa se destinavam ao seu consumo. Informou que comprou os entorpecentes dois dias antes dos fatos, pagando R\$ 220,00 pela cocaína e R\$ 80,00 pela maconha. Mencionou que usaria as drogas em cerca de um mês, e disse que usava os entorpecentes em casa.

Asseverou que não vendia drogas, e disse que quanto ao dinheiro apreendido, R\$ 100,00 eram da acusada e os R\$ 200,00 que estavam na gaveta eram seus, sendo provenientes de seus salários e destinados ao pagamento de contas. Disse, ainda, que os saquinhos plásticos eram usados para embalar "jujus".

Comentou que a movimentação que ocorria em sua casa era somente de familiares, tendo Gustavo ido ao local para pegar o telefone de seu tio, que lida com poços artesianos. Disse não saber se Gustavo é usuário de drogas e nem sabe se a polícia encontrou entorpecente com ele.

Alegou não ter ideia do motivo pelo qual foi acusado de tráfico e informou que a polícia pegou dichavador, baseado e papel de seda, mas não apreenderam tais objetos (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Por sua vez, a acusada, quando ouvida na fase policial, também negou os fatos que lhe foram imputados e sustentou que seu companheiro Gustavo de Souza Leopoldino é usuário de maconha e cocaína. Mencionou que não usa drogas e alegou que os entorpecentes encontrados em sua moradia se destinavam ao consumo de Gustavo.

Negou a prática do tráfico e informou que o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho e do de seu companheiro, sendo os saquinhos usados para embalar os geladinhos que às vezes faz para complementar a renda (fls. 17).

Em juízo, a ré também manteve essa versão, e disse que a droga apreendida em sua casa era destinada ao consumo do corréu e não para a venda. Informou que fazia quatro dias que as drogas estavam lá e disse que o acusado as usava longe da interroganda, sendo certo que ele comprava a quantidade necessária para uso no mês, para não precisar ficar comprando sempre.

Reiterou que o dinheiro apreendido era proveniente dos salários da interroganda e do acusado e disse que os saquinhos plásticos eram usados para embalar “jujus” ou sacolês, que fazia com suas afilhadas para complementar a renda. Disse que não viu a pessoa de Gustavo Ferraraz, porque chegava à noite de seu serviço (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O investigador Carlos Umberto Martins narrou que recebeu denúncia de que o acusado, que saiu da cadeia há pouco tempo, juntamente com a companheira, estariam praticando tráfico na residência deles. Disse que fez um levantamento do local, e que viu movimentação de motociclistas que desciam junto ao portão, conversavam ora com o réu, ora com a ré, e pegavam algo da mão deles.

Salientou que foi requerida busca domiciliar e disse que um rapaz, chamado Gustavo Ferraraz, que estava num veículo Palio e que entrou na casa dos réus foi abordado ao sair de tal local, sendo encontrados em sua posse três papелotes de cocaína. Mencionou que esse rapaz alegou que comprou a cocaína no bairro Recanto, em uma esquina, pelo valor de R\$ 50,00, mas disse que no trajeto feito por esse rapaz, ele não parou naquele bairro.

Comentou que em outro dia, recebeu denúncia de que o casal estava traficando à noite, ante o que foi à residência dos acusados no final da tarde, e abordou o réu, que alegou que não tinha drogas em casa. Disse que no armário da cozinha foi encontrada cocaína, sendo localizada maconha no quarto do réu. Disse, ainda, que no armário da cozinha também havia saquinhos de geladinho, que normalmente são usados para embalar as drogas.

Disse que as porções de cocaína apreendidas com Gustavo Ferraraz estavam embaladas em saquinhos. Comentou que também foi apreendido dinheiro, estando parte na mesma cômoda em que foi localizada a maconha, e a outra parte, em poder da acusada Gabriela.

Sustentou que o réu assumiu a propriedade de todas as drogas e disse ser usuário, sendo o dinheiro fruto do trabalho dele e da ré. Informou que a acusada confirmou essa mesma versão do corréu, e também disse que esporadicamente vendia geladinhos para complementar a renda. Relatou que não foram encontrados objetos para consumo de drogas.

Disse que as porções de cocaína encontradas na casa estavam embaladas em plástico transparente, de forma diversa das porções de cocaína apreendidas com Gustavo Ferraraz, que estavam acondicionadas em saquinhos de geladinho. Afirmou que não tem certeza se esse usuário comprou as drogas na casa dos réus, pois ele não pegou nada no portão, tendo entrado na casa e saído rapidamente, e não foi abordado na hora.

Mencionou que não foi encontrada balança, e disse que no exame do celular dos acusados não foi localizado nenhum conteúdo suspeito (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

No mesmo diapasão, o depoimento da investigadora Alexsandra Garcez Garcia, que

narrou que após o recebimento de denúncia anônima contra os réus, efetuou monitoramento da casa deles, e constatou a existência de movimentação estranha. Disse que chegavam motoqueiros no portão, e que os réus passavam algo para eles, após os que os motociclista iam embora.

Mencionou que no dia dos fatos, foi encontrada cocaína no armário da cozinha e maconha em uma cômoda, sendo também encontrados dinheiro e saquinhos de juju. Disse que não se recorda de como as drogas estavam acondicionadas, e comentou que a acusada disse que trabalhava e que as drogas eram do marido.

Informou que um usuário parou com o veículo na casa dos réus, foi atendido e depois foi abordado, sendo encontradas três porções de cocaína em poder dele, que eram embaladas em saquinhos, tendo esse rapaz informado que era usuário e dito que comprou a droga na vila. Destacou que depois que esse usuário saiu da casa dos réus, foi seguido, e não parou em nenhum outro local (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Por sua vez, a testemunha Gustavo Henrique Ferraraz narrou que foi abordado na posse de três porções de cocaína, que havia comprado no dia dos fatos, no Bairro Recanto, pelo valor de R\$ 50,00. Mencionou que passou pela casa dos réus para pegar o telefone do tio do acusado, que trabalha com poços artesianos.

Disse não saber se os réus têm envolvimento com drogas e explicou que mora no bairro Maestro Mourão, e que foi ao bairro Recanto, passou pela casa do seu pai e depois foi à residência dos acusados (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O depoente João Paulo Dos Santos informou que é vizinho dos réus há dois anos, e disse que eles trabalham e que sempre saem cedo de casa, não percebendo movimentação estranha na casa deles. Informou que também nunca ouviu dizer que os acusados fossem usuários de drogas (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

A testemunha Joyce Sauguéli narrou que há três anos e meio, leva a acusada de moto para trabalhar e disse que por tal motivo, ia todos os dias à casa dos réus, não tendo visto movimentação estranha. Mencionou que a ré já trabalhou em um mercado e agora faz serviços gerais, ao passo em que o réu trabalha numa firma. Alegou não saber se os acusados são usuários de drogas (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Diante de tais relatos, e considerando que além de haver denúncias de tráfico contra os acusados, durante as campanhas feitas pela polícia civil, ambos os réus foram vistos mantendo contato com motociclistas que chegavam à casa dos acusados e depois de pegarem algo com os réus, saíam do local, em movimentação característica do tráfico, na casa dos acusados foram encontradas duas porções de cocaína com peso líquido de 27,2 g e uma porção de maconha com peso líquido de 19,28 g (fls. 172 e 209), além de dinheiro, é de se entender que restou comprovada a traficância atribuída a ambos os acusados.

Essa conclusão mais se justifica porque além dos contatos e das trocas de objetos feitas entre ambos os réus e os terceiros serem característicos do tráfico, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e notadamente da cocaína, é em princípio incompatível com a que poderia ser destinada ao consumo do réu, mesmo porque embora o acusado tivesse alegado que consumia as drogas em sua casa, não foram encontrados quaisquer objetos relacionados ao uso de entorpecentes, conforme narrado pelo investigador Carlos Umberto.

E pelo contrário, foram encontrados no local saquinhos plásticos, comumente usados para embalagem de entorpecentes, não tendo a acusada comprovado suas alegações no sentido de que os usava para embalar geladinhos ou jujus que fazia para complementar a renda, já que nem mesmo as testemunhas de defesa relataram algo

nesse sentido.

Salienta-se, ainda, que embora uma das pessoas que foi vista entrando e saindo rapidamente da casa dos réus, ou seja, a testemunha Gustavo Ferraraz, tivesse alegado que as três porções de cocaína que foram encontradas em seu poder (e que coincidentemente, estavam embaladas exatamente em saquinhos de juju) não foram compradas na casa dos réus, mas sim no bairro Recanto, antes de se dirigir à casa dos acusados para pedir o telefone do tio dele, tal fato não elide a traficância atribuída aos réus, que como dito, foram vistos pelos policiais entregando algo a diversas outras pessoas.

E mesmo que o réu também fosse usuário de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a ele atribuída, porquanto não são raros os casos de usuários que também se dedicam ao tráfico, como forma de manter o próprio vício e de conseguir dinheiro sem esforço, pelo que não prospera a solução desclassificatória almejada pela Defensoria.

Observo, ainda, que apesar das testemunhas serem policiais, tal fato não pode servir para elidir a condenação dos acusados, uma vez que:

“Seria verdadeiro contra-senso que, aos agentes de segurança, deferisse o ordenamento jurídico determinada tarefa, para, depois, negar, aprioristicamente, valor a seus testemunhos, quando dela viessem prestar contas (TACRIM/SP, AC -Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 92/352)”.

Provada a autoria delitiva do tráfico, a materialidade delitiva restou confirmada pelos laudos de fls. 1721/173 e 209/210.

Todavia, os elementos constantes dos autos são insuficientes para a caracterização, com certeza, do crime de associação.

E isso se justifica porque pelo que se depreende do relato dos policiais, não há notícias de que tenha sido realizada alguma outra diligência para confirmação de que essa situação de associação dos réus para o ilícito comércio se repetia com frequência e com estabilidade, pelo que, diante da dúvida, merecem os acusados ser absolvidos quanto à imputação de terem cometido o delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, já que a mera coautoria não pode ser confundida com a associação.

Nesse sentido, confirmam-se as seguintes lições de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi (Lei de Drogas Anotada - Lei 11.343/2006, 1a ed., São Paulo, Saraiva, p. 120):

“Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência do delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria.”

Passo à fixação da pena.

Extrai-se dos autos que os acusados são primários (fls. 53/54 e 55/56), motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, fica ela mantida no mesmo patamar, dada a ausência de agravantes ou atenuantes

Diante da primariedade dos acusados, e tendo em vista que não há elementos de que eles se dedicassem a atividades delitivas (além daquela que embasa a presente condenação) ou integrassem organização criminosa, com base no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, face à quantidade de entorpecentes apreendidos, que poderiam abastecer menos de cinquenta usuários, considerando a venda de porções com 1g de droga. Desse modo, a sanção irá perfazer um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

No que pertine ao regime prisional, além do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal já terem manifestado posicionamento no sentido de que o tráfico com a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não é delito hediondo (STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 e STJ. Pet nº 11.796/DF), a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o artigo 122 da LEP, sendo previsto no § 6º de tal dispositivo, que: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Diante de tal alteração legislativa, e revendo meu anterior entendimento, como o crime em questão não é mais considerado como hediondo, face à quantidade da sanção, merece ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Salienta-se, ainda, que em que pese a redução da pena privativa de liberdade, não se mostra cabível a sua conversão em pena restritiva de direitos, pois apesar da Resolução nº 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, tal benefício não é possível diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista os efeitos nocivos do crime de tráfico de entorpecentes, que são fonte de outros tipos de criminalidade, e revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública e o bem estar social, mormente com a venda de cocaína, que é droga de maior potencial lesivo.

Assim sendo, não restaram atendidos os pressupostos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente", de modo que ainda que se cuide de delito praticado sem violência e nem grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é adequada, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Nesse sentido, já se decidiu que:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou." (STJ - HC nº 203.403/SP, C. 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/06/2011).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR GUSTAVO DE SOUZA LEOPOLDINO e GABRIELA DIAS DE FREITAS como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Fixo, para cada um dos réus, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Outrossim, ABSOLVO os acusados da imputação de terem

cometido o delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando o regime prisional fixado, concedo aos acusados o direito de apelar sem necessidade de recolhimento à prisão.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e ao cartório eleitoral, devendo, ainda, ser expedidas guias de recolhimento, mandados de prisão e termos de audiência de advertência.

Tendo em conta que os elementos constantes dos autos denotam que o dinheiro apreendido era produto do ilícito comércio, mesmo porque não foi comprovada a contento sua origem lícita, decreto o perdimento do numerário em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, ficando determinada, ainda, a destruição dos saquinhos apreendidos.

Custas, na forma da lei, ressalvada sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50, ficando deferidos aos réus os benefícios da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 30 de julho de 2022.

Elaní Cristina Mendes Marum
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA